



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

GABINETE DO CONSELHEIRO ROBSON MARINHO

Conselheiro-Substituto Antonio Carlos dos Santos

Tribunal Pleno

Sessão: **31/7/2024**

03 TC-031771/026/16 - CONSULTA

Consulente: Companhia do Metropolitano de São Paulo – METRÔ.

Assunto: Consulta acerca da correta aplicabilidade do artigo 57, § 1º, da Lei nº 8.666/93, nos casos de prorrogação em contratos por escopo.

Advogado(s): Eduardo Leandro de Queiroz e Souza (OAB/SP nº 109.013), Janaína Schoenmaker (OAB/SP nº 203.665), Alexandra Leonello Granado (OAB/SP nº 175.252) e outros.

Procurador(es) de Contas: Rafael Neubern Demarchi Costa.

Procurador(es) da Fazenda: Carim José Feres.

EMENTA: CONSULTA. LEI 8.666/1993. CONTRATO DE ESCOPO. PRORROGAÇÃO. POSSIBILIDADE. ATRASO DECORRENTE DE CULPA DA CONTRATADA. APURAÇÃO DE RESPONSABILIDADE. MANUTENÇÃO DO VÍNCULO. JURISPRUDÊNCIA.

Por intermédio de aditamento contratual, admite-se a prorrogação de contrato de escopo pelo período necessário à execução e entrega do objeto, sem prejuízo da apuração de responsabilidade nos casos de atraso atribuído à contratada.

Relatório

Em exame, **CONSULTA** formulada pela **Companhia do Metropolitano de São Paulo – METRÔ**, representada por Paulo Menezes Figueiredo, Diretor-Presidente (2015-2019), que indaga, nos termos do art. 226 do RITCESP: em qual previsão legal o METRÔ deve se basear para justificar as prorrogações dos contratos por escopo, em casos de atraso por culpa da contratada? Acrescenta que, no momento do protocolo desta **CONSULTA**, referidas prorrogações não eram formalizadas através de termos aditivos, pois o fim do prazo de execução não retira do particular a obrigação de cumprir o contrato (por se tratar de contrato por escopo, atrelado ao seu término).

Em apertada síntese, a **CONSULENTE** esclarece que, nos contratos de escopo, o término do prazo regular de vigência do contrato não acarreta, necessariamente, a extinção do vínculo, que se dá quando a



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

GABINETE DO CONSELHEIRO ROBSON MARINHO

obrigação contratual é adimplida. Nesse sentido, nos contratos de escopo, é o adimplemento do objeto contratual que determina o encerramento da avença.

Todavia, há casos em que, por exclusiva culpa da contratada, o objeto contratual não é cumprido dentro do prazo regular de vigência do vínculo. Entretanto, prossegue a **CONSULENTE**, existem situações em que, mesmo que a contratada esteja inadimplente com suas obrigações contratuais, não há vantajosidade para o METRÔ na extinção ou na interrupção do contrato sem que seu objeto tenha sido plenamente concluído. Sucede, contudo, o art. 57, § 1º da Lei 8.666/93, que trata das hipóteses que podem ensejar a prorrogação do prazo regular do contrato, não contempla a ocorrência de atraso, por culpa da contratada, como causa ensejadora da prorrogação contratual.

Nesse contexto, em que o objeto contratual não foi adimplido dentro do prazo regular de vigência, por exclusiva culpa da contratada, e em que o legítimo interesse da **CONSULENTE** recomende a continuidade do vínculo até seu pleno e integral cumprimento, remanesceria dúvida quanto à regularidade ou não da celebração de aditamento contratual, prorrogando o prazo da avença, para o fim de manter o contrato em vigor até a completa execução de seu objeto.

A **Assessoria Técnica** se manifestou, para afirmar que: **(a)** “configurada mora passível de regularização pela contratada, a aplicação de sanções contratuais corresponde a um dever da Administração e não mera faculdade (art. 92 da Lei 8.666/93)”; **(b)** o término do contrato ou a sua continuidade, após o devido processo administrativo sancionador, deve ser motivada pela contratante, evidenciando se tratar da solução que melhor atende ao interesse da Administração; e **(c)** “o atraso na execução das obras por culpa exclusiva da contratada não encontra amparo legal em nenhuma das hipóteses arroladas no § 1º do art. 57 da Lei 8.666/93” (fls. 23/43; fl. 44).



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

GABINETE DO CONSELHEIRO ROBSON MARINHO

A **Procuradoria da Fazenda do Estado** se manifestou para afirmar que:

“(…) levando em conta as ponderações e subsídios de direito e doutrinário tecidos, a falta de situação concreta e mormente considerando o caráter normativo pretendido, afigura-se que a pretendida interpretação e orientação normativa seja, num primeiro momento, de atribuição da especializada Consultoria Jurídica da Secretaria de Transportes Metropolitanos e também da Assessoria de Empresas e Fundações, que poderiam ser provocadas a emitir Parecer Jurídico sobre a matéria nos termos dos dispositivos legais supra indicados, podendo-se até mesmo ser analisado, futuramente e se o caso pela especializada Procuradoria Administrativa” (fls. 46/61).

O **Procurador-Chefe da Fazenda do Estado junto ao TCE-SP** em exercício, de seu turno, elucidou que:

“(…) abstraídas as discussões de ordem contratual e os diversos usos do negócio jurídico ante o caso concreto, sem prejuízo das providências de caráter sancionatório ou disciplinar e limitando-se aos termos dos quesitos da consulta, não resta opção, a partir da etiologia do próprio contrato por escopo e seu regramento jurídico, admitir a interpretação extensiva das hipóteses previstas no parágrafo 1º do art. 57 da Lei 8.666/93, sobretudo ante o caráter meramente formal do aditamento para fins de adaptação da vigência do contrato, ante a ausência de repercussão monetária imediata por ocasião da modificação” (fls. 124/126).

O **Ministério Público de Contas** se pronunciou, nos seguintes termos conclusivos:

“Em contratos de escopo, a extinção do contrato administrativo opera-se, normalmente, com a conclusão e entrega do objeto pela contratada e seu recebimento pela Administração.

No caso de culpa exclusiva da contratada em não cumprir os prazos de início das etapas de execução, de conclusão e de entrega, inexistindo motivos para extinção excepcional do contrato (seja pela rescisão, seja pela anulação), não há necessidade de firmar aditivo prorrogando a vigência do contrato.

Neste caso, restará inalterado o cronograma de execução, a contratada será considerada em mora (com a necessária aplicação das sanções legais e contratuais) e o contrato permanecerá vigente até sua extinção normal” (fls. 160/171).

A **Secretaria Diretoria-Geral** apresentou sua orientação, para elucidar que:

“(…) caso haja a inobservância do prazo original firmado para execução e entrega do objeto em contratos por escopo, por culpa exclusiva da contratada e, ainda assim, a Administração Pública verifique a vantagem no prolongamento da avença, que formalize o



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
GABINETE DO CONSELHEIRO ROBSON MARINHO

termo de aditamento, com base no art. 60 c/c. art. 65, II, 'b' da Lei 8.666/93, ou no art. 73 c/c. art. 81, IV da Lei 13.303/16, sem prejuízo da observância de outros dispositivos legais pertinentes a cada caso concreto" (fls. 178/193).

É o relatório.

gjj/osb



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

GABINETE DO CONSELHEIRO ROBSON MARINHO

Voto

TC-031771/026/16

Preliminar

Em preliminar, conheço da **CONSULTA**, que foi formulada por parte legítima, a fim de esclarecer dúvida de caráter geral afeta às competências desta Corte de Contas, nos termos disciplinados pelo art. 2º, XXV da Lei Complementar Estadual n. 709/1993¹ e pelo art. 226 do Regimento Interno deste e. Tribunal.²

Mérito

Trata-se de **CONSULTA** formulada pela **Companhia do Metropolitano de São Paulo – METRÔ**, para responder a seguinte pergunta: em qual previsão legal o METRÔ deve se basear para justificar as prorrogações dos contratos por escopo, em casos de atraso por culpa da contratada? Ao mesmo tempo, a CONSULENTE informa, a partir de sua prática, que a prorrogação de contratos por escopo não requer a celebração de aditamento contratual, por entender que o encerramento do contrato se aperfeiçoa apenas quando do cumprimento integral das obrigações assumidas pela contratada.

¹ Lei Complementar Estadual n. 709/1993. Art. 2º. Ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e na forma estabelecida nesta lei, compete: XXV – Decidir sobre consulta que lhe seja formulada acerca de dúvida suscitada na aplicação de dispositivos legais e regulamentares concernentes à matéria de sua competência, na forma estabelecida no Regimento Interno.

² Regimento Interno do TCE-SP. Art. 226. O Tribunal Pleno resolverá sobre as consultas que lhe forem feitas acerca de dúvidas suscitadas na aplicação das disposições legais concernentes à matéria de sua competência, desde que não envolva caso concreto ou ato consumado. § 1º O Tribunal Pleno poderá, excepcionalmente, apreciar o mérito de consulta que contenha individualização da situação fática apresentada, caso o recomende relevante razão de interesse público. § 2º As consultas, a que se refere este artigo, formuladas por intermédio dos Chefes dos Poderes Públicos estaduais e municipais, Secretários de Estado e dirigentes das entidades da administração indireta e fundacional, tanto do Estado como dos Municípios, constarão de exposição precisa da dúvida, com formulação de quesitos.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
GABINETE DO CONSELHEIRO ROBSON MARINHO

Antes de responder à **CONSULTA**, registro seu caráter abstrato e genérico. Não se trata da análise de um caso concreto ou de uma contratação específica.

Nos termos legais e regimentais, o objetivo da presente CONSULTA é estabelecer orientação geral para situações análogas em que a dúvida ora em exame se apresente. Resguardando-se, claramente, o exercício das demais competências constitucionais e legais reservadas a este e. Tribunal, por ocasião do exame dos casos concretos sob sua jurisdição.

Observa-se de início que a **CONSULTA** foi formulada a partir da disciplina estabelecida na **Lei Federal n. 8.666, de 21 de junho de 1993**, que vigorava no momento de seu protocolo, mas que foi revogada pela Lei 14.133/2021, de 1 de abril de 2021, com suas alterações. Como exposto no relatório, a **CONSULTA** se refere à prorrogação do prazo de execução dos contratos por escopo, às justificativas a serem apresentadas para tanto, e ao instrumento hábil para processá-la. Considerando que as contratações realizadas nos termos da Lei 8.666/1993 serão por ela regidas durante toda a sua vigência, nos termos do artigo 191, Parágrafo único da Lei 14.133/2021, permanece válido e pertinente o exame da matéria posta na presente **CONSULTA**. Afinal, é bastante provável que existam contratos de escopo firmados pelo METRÔ, ainda sob a vigência da Lei 8.666/1993, que permanecem em vigor e que podem vir demandar a prorrogação de prazo, nos termos formulados na **CONSULTA**.

Pelos motivos acima, não parece aqui se aplicar *integralmente* o decidido nos autos do TC-021534/026/16 (Plenário, Rel. Cons. Marco Aurélio Bertaiolli, j. 24/04/2024). Naquela oportunidade, o e. Plenário reconheceu a perda superveniente de objeto em consulta formulada a respeito do dever de publicidade na etapa de licitação, conforme a Lei 10.520/2002, que também foi revogada pela Lei 14.133/2021. Como se vê, o tema ali aventado dizia respeito



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

GABINETE DO CONSELHEIRO ROBSON MARINHO

ao dever de publicidade na etapa de licitação, que perde seu interesse futuro a partir da revogação da Lei 10.520/2002. Afinal, pela Lei 14.133/2021, não há e não haverá qualquer procedimento de nova licitação regido pela Lei 10.520/2002.

Feito o esclarecimento acima, responde-se à **CONSULTA**, registrando, de plano, a ausência de tratamento para o tema na Lei 13.303/2016, que contém o Estatuto Jurídico das empresas estatais, ao qual a CONSULENTE deve observância, por ser uma sociedade de economia mista integrante da Administração Pública indireta.

Objetivamente, os contratos de escopo se caracterizam como aqueles que “impõem ao contratado o dever de realizar a prestação de um serviço específico em período pré-determinado, podendo ser prorrogado, desde que justificadamente, pelo prazo necessário à conclusão do objeto”.³

Assim, os contratos de escopo “envolvem a entrega de um resultado final (uma obra ou bem)”⁴ necessário para o pleno atendimento da necessidade pública que o ensejou. Em outras palavras, nos contratos de escopo, a necessidade pública imediata que reclama a celebração do contrato é plenamente atendida a partir da realização do objeto contratual.

Por isso, nos contratos de escopo, o requisito de seu encerramento consiste na plena “realização do objeto pretendido”,⁵ independentemente do prazo de vigência⁶ estipulado.

³ Egon Bockmann Moreira e Flávio Garcia do Amaral. *Contratos Administrativos na Lei de Licitações – Comentários aos artigos 89 a 154 da Lei n. 14.133/2021*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2024, p.: 177.

⁴ Egon Bockmann Moreira e Flávio Garcia do Amaral. *Contratos Administrativos na Lei de Licitações – Comentários aos artigos 89 a 154 da Lei n. 14.133/2021*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2024, p.: 177.

⁵ Carlos Ari Sundfeld e Jacintho Arruda Câmara. Uma crítica à tendência de uniformizar com princípios o regime dos contratos públicos. *Revista de Direito Público da Economia – RDPE*. Belo Horizonte, ano 11, n. 41, jan./mar. 2013. Disponível em: <http://www.bidforum.com.br/bid/PDI0006.aspx?pdicntd=89215>. Acesso em: 20/05/2024.

⁶ Sobre a diferença entre prazo de vigência e prazo de execução nos contratos administrativos, Egon Bockmann Moreira e Flávio Garcia do Amaral explicam que “o contrato administrativo pode ter mais de um prazo a regular as suas



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

GABINETE DO CONSELHEIRO ROBSON MARINHO

É caso típico de contrato de escopo, por exemplo, aquele que tem por objeto a construção de um elevador em estação do METRÔ, para atender pessoas com mobilidade reduzida. A partir da conclusão do objeto do contrato – qual seja, a construção e entrega do elevador -, atende-se integralmente a necessidade pública que ensejou a celebração do contrato. Por isso, nos contratos por escopo, o seu encerramento está atrelado à entrega do objeto do contrato. Considera-se encerrado o contrato, em condições ideais, quando o objeto é entregue e aceito definitivamente pela contraparte.

Nos contratos de escopo, portanto, não é o prazo de vigência que determina – ao menos, não isoladamente – o seu encerramento, mas a efetiva entrega do objeto contratado, com vistas a atender integralmente à necessidade pública que ensejou a sua celebração.

Nas palavras de Hely Lopes Meireles:

“a extinção do contrato pela conclusão de seu objeto é a regra, ocorrendo de pleno direito quando as partes cumprem integralmente suas prestações contratuais, ou seja, a realização do objeto do ajuste por uma delas e o pagamento do preço pela outra. Concluído o objeto do contrato, segue-se sua entrega pelo contratado, e recebimento pela Administração, mediante ‘termo’ ou simples ‘recibo’, como vimos acima. O recebimento definitivo importa o reconhecimento da conclusão do objeto do contrato, operando sua extinção”⁷ [destaque acrescido].

É claro que, nos contratos de escopo, é importante observar o prazo avençado para o cumprimento das obrigações. Mas não é ele – o prazo – que define, sozinho, o momento do encerramento do contrato. Nos contratos de escopo, o prazo serve mais ao acompanhamento de sua execução e de

disposições. É bastante comum que determinados contratos prevejam prazo de vigência (duração temporal do contrato) e prazo de execução (período no qual as obrigações de ambas as partes deverão ser cumpridas). Suponha-se, por exemplo, contrato de obra pública. Pode-se cogitar de prazo de execução que circunscreverá o período para o adimplemento das obrigações e prazo de vigência (normalmente, mais extenso), que viabilize o recebimento provisório e definitivo da obra. Mesmo após o cumprimento das obrigações contratuais, poderão remanescer providências administrativas a serem adotadas que justifiquem a previsão de um prazo de vigência maior do que o prazo de execução”. Egon Bockmann Moreira e Flávio Garcia do Amaral. *Contratos Administrativos na Lei de Licitações – Comentários aos artigos 89 a 154 da Lei n. 14.133/2021*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2024, p.: 155.

⁷ Hely Lopes Meirelles. *Direito Administrativo Brasileiro*. São Paulo: Malheiros Editores, 33ª edição, 2007, p. 233.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

GABINETE DO CONSELHEIRO ROBSON MARINHO

aferição do atendimento dos direitos e deveres pelas partes, a tempo e hora, conforme definido no momento da assinatura do contrato, do que à demarcação temporal de sua vigência. Nesse sentido são as palavras de Egon Bockmann Moreira e Flávio Garcia do Amaral, para quem **“o prazo, no contrato por escopo, não é, portanto, elemento essencial do negócio jurídico, não sendo o seu exaurimento causa extintiva do contrato”** [destaque acrescido].⁸

Endossando a orientação acima, ao demarcar a distinção entre contratos de escopo e contratos de serviços contínuos, estes últimos não abrangidos pela **CONSULTA** ora em apreciação, Celso Antônio Bandeira de Mello afirma que:

“a diferença aludida [entre contrato de escopo versus contrato de serviços contínuos], portanto, não é, de modo algum, a existência ou não de prazo, mas o fato de que em um tipo [contrato de escopo] o que se pretende é um objeto concluído”.⁹

Assim, nos contratos de escopo, o prazo determina o tempo concedido à contratada para entregar o objeto. Por isso, costuma-se dizer que, nos contratos de escopo, o prazo tem caráter moratório. Logo, em caso de descumprimento dos prazos contratualmente estabelecidos, o próprio contrato – e a lei – podem prever consequências, geralmente de índole sancionatória pelo não cumprimento do contrato no período avençado.

É essa a lição de Carlos Ari Sundfeld e Jacintho Arruda Câmara. Confira-se:

“A plena execução dos contratos por escopo é determinada pela realização de objeto preestabelecido. Mesmo havendo prazo para conclusão do pactuado, o decurso do tempo não é em si suficiente para extinguir a avença. O prazo é estabelecido como obrigação do contratado e não como elemento para determinar a extinção

⁸ Egon Bockmann Moreira e Flávio Garcia do Amaral. *Contratos Administrativos na Lei de Licitações – Comentários aos artigos 89 a 154 da Lei n. 14.133/2021*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2024, p.: 177.

⁹ Celso Antônio Bandeira de Mello. *Curso de Direito Administrativo*. São Paulo: Malheiros, 28ª edição, 2011, p.: 634.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

GABINETE DO CONSELHEIRO ROBSON MARINHO

do contrato pelo seu pleno cumprimento. É o que se dá nos contratos de empreitada de obra pública. A execução do contrato e, conseqüentemente, a extinção decorrente de sua plena eficácia se dão com a construção da obra em si. O transcurso do prazo contratual é relevante para apurar o cumprimento da obrigação do contratado, mas não basta para extinguir a avença”.¹⁰

Assim, pode-se dizer que, nos **contratos de escopo**, é a “plena realização do objeto” que determina e condiciona o seu encerramento. O prazo avençado para tanto é, claro, importante. Mas não para saber se o contrato permanece ou não em vigor, e sim para avaliar o regular cumprimento das obrigações estabelecidas entre as partes.

É essa a orientação deste e. **Tribunal de Contas do Estado de São Paulo**, conforme se pode extrair dos excertos a seguir ilustrativamente reproduzidos:

TCE-SP. TC-008892.989.19-5. Primeira Câmara. Rel. Cons. Sidney Estanislau Beraldo, 07/06/2022:

“Ademais, entendo que se trata de **contrato de escopo**, no qual, inexistindo motivos para rescisão ou anulação, **a extinção do ajuste somente se opera com a conclusão do objeto e o seu recebimento pela Administração.** Para esse tipo do avença, o tempo não implica, necessariamente, no encerramento das obrigações contratuais assumidas pelas partes contratantes”.

TCE-SP. TC-025279.989.18-0. Segunda Câmara. Rel. Cons. Dimas Ramalho, 27/08/2019:

“Trata-se, o caso em exame, de **contrato de escopo**, no qual a Administração Pública busca para seu patrimônio um objeto certo e acabado. Neste tipo de contrato, em face da sua natureza jurídica, **só haverá extinção natural da avença com o término de seu objeto**, ou seja, o contratado deverá realizar todas as condutas previamente estabelecidas no procedimento licitatório”.

TCE-SP. TC-020392.026.15. Primeira Câmara. Rel. Cons. Renato Martins Costa, 05/09/2017:

¹⁰ Carlos Ari Sundfeld e Jacintho Arruda Câmara. Uma crítica à tendência de uniformizar com princípios o regime dos contratos públicos. *Revista de Direito Público da Economia – RDPE*. Belo Horizonte, ano 11, n. 41, jan./mar. 2013. Disponível em: <http://www.bidforum.com.br/bid/PDI0006.aspx?pdiCntd=89215>. Acesso em: 20/05/2024.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

GABINETE DO CONSELHEIRO ROBSON MARINHO

“A esse respeito, como bem asseverou a Assessoria Técnica desta E. Corte, a natureza do objeto avençado acaba por subsumir a avença em exame no conceito de **contrato de escopo**, cuja **extinção não decorre do esaurimento do prazo de execução, mas da efetiva entrega dos produtos**”.

E a orientação do **Tribunal de Contas da União**, igualmente, não diverge da que vigora nesta Corte Bandeirante, como se pode perceber dos trechos exemplificativamente reproduzidos abaixo. Confira-se:

TCU. Acórdão 127/0216. Plenário. Rel. Min. Subs. André de Carvalho, 27/01/2016:

“(…) nos chamados contratos por escopo (em que o objeto consistiria na obtenção de um bem ou construção de uma obra), **o prazo de execução só seria extinto quando o objeto fosse definitivamente entregue à administração e as demais obrigações fixadas no ajuste fossem plenamente satisfeitas, de modo que, inexistindo motivos para rescisão ou anulação, a extinção desse tipo de ajuste somente se operaria com a conclusão do objeto e com o seu recebimento definitivo pela administração**, diferentemente do que ocorreria nas avenças por tempo determinado (em que o objeto consistiria na prestação de serviços contínuos), nos quais o prazo constituiria elemento essencial e imprescindível para a consecução ou eficácia do objeto avençado” [destaque acrescido].

TCU. Acórdão 479/2015. Plenário. Rel. Min. Benjamin Zymler, 11/03/2015:

“Nos **contratos de escopo**, o órgão contratante objetiva a obtenção de um determinado bem ou serviço, de forma que o ajuste estará adimplido apenas quando concluída a execução e recebido o seu objeto. **O prazo contratual tem importância apenas para que a Administração possa exigir do particular o cumprimento de suas obrigações no prazo acordado**”.

TCU. Informativo n. 203. Sessões de 24 a 25 de junho de 2014. Acórdão 1674/2014. Plenário. Rel. Min. José Mucio Monteiro, 25/06/2014:

“Nos **contratos por escopo**, inexistindo motivos para sua rescisão ou anulação, a extinção do ajuste somente se opera com a conclusão do objeto e o seu recebimento pela **Administração**, diferentemente dos ajustes por tempo determinado, nos quais o prazo constitui elemento essencial e imprescindível para a consecução ou a eficácia do objeto avençado”. [destaque acrescido].



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

GABINETE DO CONSELHEIRO ROBSON MARINHO

Nos contratos de escopo, portanto, pode acontecer um “descolamento” entre o prazo de sua vigência e o tempo necessário à conclusão do objeto. Por certo, não é desejado que exista esse tipo de desencontro. Entretanto, como sói ocorrer em qualquer empreendimento – do mais modesto, como a pintura de um cômodo em uma residência, ao mais complexo, como a execução de obras metroviárias - podem suceder eventos e circunstâncias não previstos anteriormente, retardando o prazo de execução inicialmente estimado.

Por isso, a própria Lei 8.666/1993 prevê, em seu art. 57, § 1º, algumas situações fáticas que podem ensejar a prorrogação dos prazos contratuais.¹¹ As hipóteses elencadas no referido dispositivo legal se referem, de um lado, aos casos de atrasos na execução decorrentes de eventos alheios à vontade das partes e, de outro lado, às situações em que a demora percebida foi originária de ato da Administração.

Nos primeiros casos, de atrasos decorrentes de eventos alheios às partes, estão as situações descritas no art. 57, § 1º, II (superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições de execução do contrato); e no art. art. 57, § 1º, V (impedimento de execução do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela Administração em documento contemporâneo à sua ocorrência).

¹¹ Lei 8.666/1993. Art. 57, § 1º - Os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de entrega admitem prorrogação, mantidas as demais cláusulas do contrato e assegurada a manutenção de seu equilíbrio econômico-financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente autuados em processo: I - alteração do projeto ou especificações, pela Administração; II - superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições de execução do contrato; III - interrupção da execução do contrato ou diminuição do ritmo de trabalho por ordem e no interesse da Administração; IV - aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos por esta Lei; V - impedimento de execução do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela Administração em documento contemporâneo à sua ocorrência; VI - omissão ou atraso de providências a cargo da Administração, inclusive quanto aos pagamentos previstos de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na execução do contrato, sem prejuízo das sanções legais aplicáveis aos responsáveis.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

GABINETE DO CONSELHEIRO ROBSON MARINHO

Já os casos de atrasos provenientes de ato da Administração estão descritos no art. 57, § 1º, I (alteração do projeto ou especificações, pela Administração); art. 57, § 1º, III (interrupção da execução do contrato ou diminuição do ritmo de trabalho por ordem e no interesse da Administração); art. 57, § 1º, IV (aumento nos quantitativos inicialmente pactuados, nos limites legais); e art. 57, § 1º, VI (omissão ou atraso de providência a cargo da Administração).

Como anotou a própria CONSULENTE, não se observa, dentre as hipóteses previstas na norma acima referenciada, menção às hipóteses de atraso na execução contratual em decorrência de culpa ou falha atribuída à contratada. Em situações tais, contudo, pela natureza do contrato de escopo, a solução não é diferente daquela enunciada pelo art. 57, § 1º, já exposta anteriormente: preserva-se o ajuste celebrado, dilatando o prazo do contrato, apurando-se a ocorrência de falha ou culpa da contratada que contribuíram ou deram causa ao atraso ensejador da extensão de seu prazo. Nesse sentido, aliás, foi a manifestação do d. Procurador-Chefe da Procuradoria da Fazenda do Estado, conforme exposto no relatório. Mesmo nos casos em que o atraso na execução do contrato seja decorrente de culpa ou falha da contratada, a manutenção do vínculo se impõe, até o adimplemento integral das obrigações estipuladas, com a necessária extensão do prazo do contrato e a inescapável apuração de responsabilidades pela demora verificada.

A literatura clássica do Direito Administrativo brasileiro corrobora o quanto aqui exposto a respeito da prorrogação do prazo de contrato de escopo, mesmo nos casos de culpa ou falha da contratada. É Celso Antônio Bandeira de Mello quem diz:

[se o] “objeto não for concluído no prazo, não há exaustão do propósito contratual, daí a necessidade de sua prorrogação (**com ou sem sanção para o contratado, dependendo das hipóteses**) ou, então, realização de nova licitação para conclusão do objeto. Aliás, a



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

GABINETE DO CONSELHEIRO ROBSON MARINHO

própria lei prevê a prorrogação do contrato nos casos especificados no § 1º do o art. 57” [destaque acrescido].¹²

As considerações acima encontram eco em pronunciamentos recentes deste e. **Tribunal de Contas do Estado de São Paulo**, como se depreende do excerto abaixo:

TCE-SP. TC-034209.026.11. Primeira Câmara. Rel. Cons. Sidney Estanislau Beraldo, 13/09/2022:

“Não obstante os aspectos favoráveis, oportuno ressaltar que por se tratar de **contrato de escopo**, consoante já destacado no voto anteriormente prolatado (fls. 6857/6860), o **aditivo em questão objetivou, mais uma vez, a prorrogação do prazo de vigência** para a conclusão dos serviços, atingindo o total de 136 meses daqueles 57 inicialmente previstos, tendo as justificativas de fls. 6925/6932 **registrado a responsabilidade do Consórcio no descumprimento dos prazos estabelecidos**.

Desta feita, **recomendo à Companhia que adote as providências pertinentes no sentido de apurar responsabilidades e eventualmente aplicar as penalidades contratuais pertinentes em razão da mencionada mora do Contratado**”.

TCE-SP. TC-025279.989.18, 2ª Câmara. Rel. Cons. Dimas Eduardo Ramalho, 27/08/2019:

“Ressalte-se, no entanto, a necessidade do Contratante adotar as providências necessárias para **apurar as reais razões do descumprimento do prazo inicial do contrato, aplicando-se as penalidades contratuais em razão da mora**, o que merece ser destacado como ressalva e recomendação para casos futuros”.

Afinal, é da natureza dos contratos de escopo ter seu encerramento e conclusão atrelados à entrega do correspondente objeto. Daí porque, nos casos em que a superveniência de circunstâncias ou eventos impeçam ou retardem o cumprimento dos prazos em contratos de escopo, admite-se a sua prorrogação, mesmo quando o atraso percebido decorrer de falha ou culpa da contratada. Entender o contrário importaria em subtrair da

¹² Celso Antônio Bandeira de Mello. *Curso de Direito Administrativos*. São Paulo: Malheiros, 28ª edição, 2011, pp.: 634-635.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
GABINETE DO CONSELHEIRO ROBSON MARINHO

Administração, e de seu contratado, a oportunidade de concluir o objeto já em plena execução, no tempo estendido, prorrogado, necessário para tanto.

É verdade que, alternativamente, admite-se a celebração de um verdadeiro novo contrato, para concluir o objeto em atraso previsto em contrato de escopo. O novo contrato poderia ser feito por intermédio do necessário procedimento de seleção do contratado, por licitação ou contratação direta, com todos os requisitos necessários: cumprimento das exigências da fase interna (ou da fase preparatória, na dicção da Lei 14.133/2021), divulgação do aviso de edital (ou de contratação direta), recebimento de impugnações e pedidos de esclarecimentos, recursos administrativos etc. Após a conclusão de todo esse *iter*, remanesceriam ainda as dificuldades inerentes à assunção de um empreendimento em execução por um novo executor. E mais: haveria ainda a necessidade de apurar as consequências derivadas da extinção do contrato de escopo antes da conclusão de seu objeto, com eventuais indenizações e litígios. A esse propósito, imperioso lembrar: na disciplina da Lei 14.133/2021, a declaração de extinção do contrato administrativo por irregularidades – inclusive provenientes de falha ou culpa da contratada - deve levar em consideração as consequências práticas da decisão, à luz do disposto nos artigos 20 e 21 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro¹³ e dos incisos que completam o *caput* do art. 147 da NLLC.¹⁴

¹³ LINDB. Art. 20. Nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão. Parágrafo único. A motivação demonstrará a necessidade e a adequação da medida imposta ou da invalidação de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, inclusive em face das possíveis alternativas. Art. 21. A decisão que, nas esferas administrativa, controladora ou judicial, decretar a invalidação de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa deverá indicar de modo expresso suas consequências jurídicas e administrativas. Parágrafo único. A decisão a que se refere o caput deste artigo deverá, quando for o caso, indicar as condições para que a regularização ocorra de modo proporcional e equânime e sem prejuízo aos interesses gerais, não se podendo impor aos sujeitos atingidos ônus ou perdas que, em função das peculiaridades do caso, sejam anormais ou excessivos.

¹⁴ Lei 14.133/2021. Art. 147. Constatada irregularidade no procedimento licitatório ou na execução contratual, caso não seja possível o saneamento, a decisão sobre a suspensão da execução ou sobre a declaração de nulidade do contrato somente será adotada na hipótese em que se revelar medida de interesse público, com avaliação, entre outros, dos seguintes aspectos: I - impactos econômicos e financeiros decorrentes do atraso na fruição dos benefícios do objeto do contrato; II - riscos sociais, ambientais e à segurança da população local decorrentes do atraso na fruição dos benefícios do objeto do contrato; III - motivação social e ambiental do contrato; IV - custo da deterioração ou da perda



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

GABINETE DO CONSELHEIRO ROBSON MARINHO

Não parece este o propósito do “dever de licitar” e dos contratos administrativos em geral, que têm na prestação de serviços de interesse público e no atingimento das finalidades públicas pretendidas pela ação estatal a sua razão de existir: “o dever jurídico fundamental de todo gestor público é cumprir, a tempo, os seus deveres finalísticos (entregar serviços à população, prover a máquina pública daquilo que ela precisa para atuar etc.). Seguir demandas e cumprir formalidades da legislação de contratações – isto é, atentar para os meios – é, naturalmente, recomendável e bastante útil. Mas isso nunca se sobrepõe aos deveres finalísticos, na forma como tiverem sido dispostos na legislação que os prevê”.¹⁵ Não é à toa que, na disciplina da Lei 14.133/2021, vigora o princípio da preservação dos contratos, positivamente consagrado, sucedâneo que é do princípio basilar da segurança jurídica (art. 147, Parágrafo único).

Por essas razões, mesmo nos casos de atrasos na execução do objeto em decorrência de falhas cometidas pela contratada, configurado o interesse legítimo da Administração e verificada a vantajosidade, admite-se a prorrogação desses ajustes de escopo, sem prejuízo da apuração de responsabilidades e de eventual aplicação de sanção.

Todavia, caso se verifique, a partir do atraso, circunstâncias impeditivas da manutenção do vínculo, a Administração deverá proceder à sua rescisão. Nessa situação extrema, observando-se, conforme a legislação de

das parcelas executadas; V - despesa necessária à preservação das instalações e dos serviços já executados; VI - despesa inerente à desmobilização e ao posterior retorno às atividades; VII - medidas efetivamente adotadas pelo titular do órgão ou entidade para o saneamento dos indícios de irregularidades apontados; VIII - custo total e estágio de execução física e financeira dos contratos, dos convênios, das obras ou das parcelas envolvidas; IX - fechamento de postos de trabalho diretos e indiretos em razão da paralisação; X - custo para realização de nova licitação ou celebração de novo contrato; XI - custo de oportunidade do capital durante o período de paralisação. Parágrafo único. Caso a paralisação ou anulação não se revele medida de interesse público, o poder público deverá optar pela continuidade do contrato e pela solução da irregularidade por meio de indenização por perdas e danos, sem prejuízo da apuração de responsabilidade e da aplicação de penalidades cabíveis.

¹⁵ Carlos Ari Sundfeld e Guilherme Jardim Jurksaitis. “Fase preparatória – Comentários aos artigos 18 a 27 da nova lei de licitações” in Augusto Neves Dal Pozzo; Márcio Cammarosano; Maurício Zockun. (Org.). *Lei de Licitações e Contratos Administrativos Comentada - Lei 14.133/21*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1ª edição, 2021, p.: 165.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

GABINETE DO CONSELHEIRO ROBSON MARINHO

regência, o disposto no art. 147 a 149 da Lei 14.133/2021. Nesses casos, nas palavras de Luciano Ferraz, “cabe à Administração, em juízo de proporcionalidade, decidir pela extinção do contrato ou pela adoção de medidas próprias à continuidade da execução contratual (com a aplicação de penalidade, por exemplo)”.¹⁶

Atente-se que a prorrogação do contrato de escopo não modifica o seu objeto, que permanece o mesmo, porém, com prazo de execução dilatado pelo período necessário para a sua efetiva entrega. É dizer, a prorrogação do contrato de escopo presta-se a viabilizar a conclusão das etapas necessárias à execução do objeto. Por esse motivo, nos contratos de escopo, a prorrogação do prazo do contrato não modifica ou altera o seu objeto.

Consequentemente, devem ser ínfimos os efeitos orçamentários e financeiros da prorrogação, proporcionais e limitados às providências formais necessárias para a manutenção do contrato pelo período estendido necessário para a efetiva conclusão do objeto. A dilação de prazo, nesses casos, serve exclusivamente para viabilizar a conclusão e a entrega do objeto contratado.

Desta feita, não se admite que a Administração venha a suportar consequências econômico-financeiras provenientes de atrasos decorrentes na execução do contrato por culpa ou falha exclusivamente atribuída à contratada. Assim, caso se verifique, por intermédio de regular processo administrativo, que o atraso decorreu de culpa ou falha da contratada, a Administração deve declarar a mora e aplicar as sanções cabíveis, com a continuidade do pacto.

Em sintonia com a manifestação da Secretaria-Diretoria Geral, em qualquer hipótese, a prorrogação de prazo de contrato de escopo deve ser

¹⁶ Luciano Ferraz. “Contratos na Nova Lei de Licitações e Contratos” in Maria Sylvia Zanella Di Pietro (coord.). *Manual de Licitações e Contratos Administrativos – Lei 14.133, de 1 de abril de 2021*. São Paulo: Editora Forense, 3ª edição, 2023, p.: 402.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

GABINETE DO CONSELHEIRO ROBSON MARINHO

formalizada por instrumento próprio, o aditamento contratual, conforme os artigos 60, 62 e 65, II, 'b' da Lei 8.666/1993 e os artigos 91 e 94 da Lei 14.133/2021. Essa é a orientação do **Tribunal de Contas da União**, reproduzida abaixo, e deste **Tribunal de Contas do Estado de São Paulo**, como se poderá ler mais adiante:

TCU. Acórdão 127/2016. Plenário. Rel. Min. Subs. André de Carvalho, 27/01/2016:

Com efeito, a jurisprudência desta Corte de Contas se consolidou ao longo do tempo no sentido de **considerar irregular o aditamento feito após o término da vigência contratual**, ainda que amparado em um dos motivos do art. 57, § 1º, da Lei nº 8.666, de 1993, uma vez que o contrato original estaria formalmente extinto, de sorte que não seria juridicamente cabível a sua prorrogação ou a continuidade da sua execução (v.g.: Acórdãos 66/2004, 1.717/2005, 216/2007, 1.335/2009, 1.936/2014 e 2.143/2015, todos do Plenário do TCU).

TCE-SP. TC-021977.026.10. Segunda Câmara. Rel. Cons. Antonio Roque Citadini, 19/07/2016:

Quanto esta ausência de termos de recebimento dos serviços, acompanho SDG que entende que: (...) “não obstante, penso **que a celebração de termos de prorrogação de prazo não é dispensável para os contratos de escopo**, a exemplo do decidido no TC1978/003/10, desse modo, entendo que cabe advertência ao METRÔ, uma vez que, em suas justificativas datadas de 02/02/2015, informou que o contrato se encontra em execução, no entanto, o último termo juntado aos autos prorrogou o prazo até 17/06/2013. Assim **deve adotar providências para a formalização da prorrogação da vigência do contrato e da execução**, até que possam ser emitidos os termos de recebimento provisório e definitivo”. [destaque acrescido]

TCE-SP. TC-001978.003.10. Segunda Câmara. Rel. Cons. Sidney Estanislau Beraldo, 18/03/2014:

Sem embargo, **o fato de se tratar de contrato de escopo não significa que a celebração do aditivo seja desnecessária ou dispensável, devendo nele constar a hipótese ensejadora da dilação**, consoante rol do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666/93, nem tampouco que a expiração do limite temporal estabelecido implique, per se, o encerramento das obrigações, sendo que, como ensina Joel de Menezes Niebuhr, “o tempo apenas caracteriza ou não a mora do contratado”. [destaque acrescido]



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

GABINETE DO CONSELHEIRO ROBSON MARINHO

Em face do acima contido, tem-se a imprescindibilidade da celebração de aditamento de extensão de prazo em contrato de escopo. O aditamento deve ser precedido dos estudos e levantamentos que evidenciem as causas do atraso, a vantajosidade da manutenção do vínculo à luz do interesse público, e a correção das providências adotadas para sua conclusão, inclusive quanto à apuração de responsabilidades. Esses estudos e levantamentos devem ser acompanhados das memórias de cálculo e dos elementos técnicos que lhe suportem.

Assim, para que se proceda à prorrogação do contrato de escopo, mas também de serviços contínuos, a Administração deve agir com antecedência e planejamento. Espera-se que o edital de licitação contemple as hipóteses de prorrogação contratual e a indicação dos requisitos necessários para a sua legítima celebração. Igualmente, a Administração deve elaborar os estudos e minutas de aditamentos necessários à prorrogação tempestivamente, evitando relegar essas providências para a “última hora”.

Novamente, são essas as orientações de Egon Bockmann Moreira e Flávio Garcia do Amaral:

“Recomendável, ainda, que a previsão de prorrogação (no edital ou no contrato) não seja genérica, mas com a fixação dos requisitos e das condições para que o prolongamento do contrato administrativo se efetive. A formalização da prorrogação se aperfeiçoa por meio de termo aditivo, que deve estar amparado em decisões administrativas prévias e motivadas que legitimem a opção pela prorrogação do contrato (...).

A boa gestão dos contratos impõe antecedência no exame das possíveis prorrogações. O princípio da eficiência não autoriza que os procedimentos para a definição da prorrogação ou não do contrato administrativo sejam instalados muito próximos da data de encerramento do contrato, ensejando prorrogações com deficiência na sua instrução ou mesmo com avaliações precárias ou emergenciais que podem desatender ao interesse público”.¹⁷

¹⁷ Egon Bockmann Moreira e Flávio Garcia do Amaral. *Contratos Administrativos na Lei de Licitações – Comentários aos artigos 89 a 154 da Lei n. 14.133/2021*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2024, pp.: 164-165.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

GABINETE DO CONSELHEIRO ROBSON MARINHO

As considerações acima apresentadas aplicam-se indistintamente aos contratos regidos pela Lei 8.666/1993, que vigorava no momento da apresentação da **CONSULTA**, e pela Lei 14.133/2021. Todavia, nesta última sobressaem aspectos relevantes, e que devem ser levados em consideração na presente **CONSULTA**.

Em diversos temas, a Lei 14.133/2021 incorporou em seu texto orientações do Tribunal de Contas da União e da literatura. Não foi diferente com os contratos de escopo. Observa-se que a Lei 14.133/2021 é taxativa ao reconhecer a possibilidade de prorrogação **automática** dos contratos de escopo pelo período necessário à sua conclusão (art. 6º, XVII e art. 111, *caput*). Além disso, a Lei 14.133/2021 determina que, quando o atraso na execução do contrato decorrer de culpa do contratado, que a Administração o constitua em mora e aplique as correspondentes sanções administrativas (art. 111, Parágrafo único).

Desse modo, verifica-se que a prorrogação de contratos de escopo, pelo período necessário à conclusão e entrega de seu objeto, está expressamente autorizada pelo ordenamento jurídico vigente, independentemente dos motivos causadores do atraso que ensejou a prorrogação contratual.

Na **CONSULTA** ora em apreciação, as judiciosas manifestações dos órgãos técnicos e de assessoramento revelam clara sintonia. As manifestações contidas nos autos reconhecem **(i)** a possibilidade de prorrogação de contratos de escopo pelo período necessário à conclusão de seu objeto, **(ii)** sem prejuízo da apuração de responsabilidade e aplicação de sanção em caso de culpa ou falha da contratada. Igualmente, a instrução converge que **(iii)** a prorrogação de contrato de escopo deve ser feita por intermédio de termo de aditamento, e **(iv)** sem ônus adicionais para a Administração.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
GABINETE DO CONSELHEIRO ROBSON MARINHO

Ante o exposto, limitada a **CONSULTA** aos pontos estrita e abstratamente suscitados, acolho a instrução e submeto ao Colegiado as seguintes conclusões:

P.1: *Em qual previsão da Lei 8.666/93 pode ser admitida a prorrogação de contratos de escopo, em casos de atraso por falha ou culpa da contratada?*

R.1: Admite-se a prorrogação de contratos de escopo, inclusive nos casos em que o atraso causador da prorrogação decorrer de falha ou culpa atribuída à contratada, pelo prazo necessário à conclusão e entrega de seu objeto, em interpretação extensiva do art. 57, § 1º da Lei 8.666/93, apoiada no disposto no art. 6º, XVII e no art. 111, *caput*, da Lei 14.133/2021.

P.2: *É necessário formalizar termo de aditamento para a prorrogação de prazo de contratos de escopo, em que o atraso decorreu de falha ou culpa da contratada?*

R.2: A prorrogação do contrato de escopo, em qualquer caso, deve ser feita por intermédio de termo de aditamento, devidamente instruído com as memórias de cálculo e os elementos técnicos que lhe deem suporte, evidenciando as razões de interesse público atendidas e que reclamaram a manutenção e a continuidade do vínculo.

P.3: *Deve-se instaurar procedimento administrativo para apuração do descumprimento contratual e aplicar as penalidades cabíveis no caso de atraso na execução do contrato de escopo que decorreu de falha ou culpa da contratada?*

R.3: Quando o atraso que ensejou a prorrogação decorrer de falha ou culpa da contratada, a Administração deve instaurar o devido processo administrativo para apuração de responsabilidade, declarar a contratada em mora e adotar as consequências legais pertinentes.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
GABINETE DO CONSELHEIRO ROBSON MARINHO

É como respondo à CONSULTA.